

1500715-77.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500715-77.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500715-77.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2046333/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 16284700 - DEL.POL.CUBATÃO, 165/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2046333 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EDSON DE OLIVEIRA GOMES e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

EDSON DE OLIVEIRA GOMES e WESLEY OLIMPIO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

Narra a peça incoativa que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 23h27, na Avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao nº 445, Jardim 31 de Março, Cubatão, EDSON DE OLIVEIRA GOMES e WESLEY OLIMPIO DA SILVA, qualificados a fls. 61 e 74, agindo em concurso, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram subtrair, para todos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12), uma motocicleta,

pertencente à vítima não identificada, não se consumando por circunstâncias alheias as suas vontades. Segundo o narrado, os Réus transitavam pelo local dos fatos, em uma moto, marca Honda/CG Titan, placas DZN-1266, momento em que visualizaram um casal, em uma outra moto (Yamaha/Fazer, cor preta, placa não anotada) parados, e resolveram, então, em conluio, praticar crime patrimonial. Ato contínuo, os denunciados se aproximaram e cercaram o casal, tendo EDSON com nítida divisão de tarefas, anunciado o assalto, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, enquanto WESLEY dava a devida cobertura. Ocorre que vigilantes da Petrobrás realizavam ronda, pelo local, tendo observado a prática delitiva. Ao avistar, então, a aproximação dos mesmos, o denunciado EDSON correu em direção à motocicleta, conduzida pelo denunciado WESLEY, visando empreender em fuga. Ao empreender fuga, portanto, em alta velocidade, o denunciado WESLEY perdeu o controle da moto, vindo a cair com EDSON, que estava na garupa. Consequentemente, foram alcançados e presos em flagrante, juntamente com o simulacro de arma de fogo utilizado, não tendo, assim, o crime se consumado. As vítimas, ao avistarem os vigilantes, vislumbrando a fuga dos assaltantes, saíram do local, sem serem identificadas.

A denúncia foi recebida (art. 396 do CPP) em 25 de fevereiro de 2021 (fls. 126/128).

Citados (art. 351 do CPP), os Réus Wesley e Edson apresentaram resposta à acusação (art. 396-A do CPP) às (fls. 186/191 e 192/194).

Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) (fls. 213/216).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, não sendo o caso de diligências complementares (art. 402 do CPP), o Ministério Público apresentou alegações finais (art. 403 do CPP), pugnando pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa de Wesley Olímpio da Silva (fls. 486-495), por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e regime inicial diverso do fechado.

De seu turno, a Defesa de Edson de Oliveira Gomes (fls. 506-507) requer a absolvição por insuficiência probatória.

Eis o breve relato do necessário.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório dos acusados.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Afasto a nulidade aventada quanto ao reconhecimento pessoal, heis que foram seguidos todos os ditames legais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do

CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas.

Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos investigativos colhidos em sede inquisitorial: Boletim de ocorrência (fls. 03-10), auto de exibição/apreensão (fls. 11-12), termos de depoimento (fls. 13-19), relatório final (fls. 79-85), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição aos réus, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha ERICK FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA, policial militar, disse que se recorda da ocorrência dos fatos. Estavam em patrulhamento quando COPOM irradiou a ocorrência. Foram recebidos pela equipe de vigilância, quando chegaram ao local. Foi solicitado resgate médico, porque um dos Réus estava, aparentemente, com o braço quebrado. Informalmente confessaram o roubo. As vítimas não foram localizadas, evadindo-se do local. Salvo engano os vigilantes estavam prestando um serviço para a Petrobrás. Quando saíram, perceberam que os Réus estavam numa aparentemente tentativa de roubo. Não sabe dizer se os vigilantes efetuaram o reconhecimento dos Réus. Wesley, quando caiu, estava com uma dor no braço. Não percebeu se teve algum membro quebrado. O próprio réu disse que talvez tivesse quebrado o braço com a queda. Não estava sangrando. Edson também se machucou, estava com a face bem machucada, mas nada fraturado, aparentemente. Wesley disse que estaria realizando um serviço de mototáxi. Edson havia oferecido dinheiro para efetuar uma corrida para Cubatão para visitar uma ex-esposa ou algo assim. Edson, informalmente, disse que foi ao local para tentar o roubo em uma motocicleta mas não deu certo. Edson não informou que Wesley estava em concurso de agentes. Foram informados que os Réus eram moradores de Garujá. Edson disse que veio de Garujá com Wesley em mototáxi. Edson permaneceu calado, não disse se Wesley participou do crime. Ninguém chegou a agredi-los.

Em juízo, a testemunha THAIS FERNANDA ESTEVAM, policial militar, disse que reconhece os Réus de uma ocorrência de tentativa de roubo. Na data dos fatos foi irradiado, via copom, que estava ocorrendo um roubo na Avenida Cruzeiro do Sul. Chegando ao local dos fatos havia 3 vigilantes, uma moto caída e os dois Réus, presos. Um simulacro de arma de fogo estava nas proximidades. Não se recorda quem acionou a polícia. Os vigilantes relataram que estavam realizando patrulhamento na localidade, próximo ao oleoduto, quando visualizaram dois indivíduos tentando roubar uma motocicleta. Os réus tentaram se evadir de motocicleta mais caíram e foram presos pelos vigilantes. Os réus caíram de modo e estavam com escoriações. Não se recorda se alguém reclamou de estar com o braço quebrado. Foi acionado o

SAMU para socorrer-los. O Réu Wesley, que estava pilotando a motocicleta, disse que trabalhava em uma pizzaria. O outro Réu disse que pagaria R\$ 100,00 para levá-lo em um local. O garupa, Sr. Edson, disse que tinha a intenção de roubar a motocicleta. O Réu Edson não falou nada do Sr. Wesley ser seu comparsa. Não confirmou ter pego carona com o outro Réu, apenas disse que era seu amigo. Não conhecia os Réus. Em nenhum momento os Réus foram agredidos pela polícia ou vigilantes. Os vigilantes falaram que presenciaram o roubo por parte dos dois Réus.

Em juízo, a testemunha ERICK PEREIRA DE MENEZES disse que trabalhava em uma empresa subsidiária da Petrobrás. Estavam realizando uma faixa no Km 09. Não se recorda o nome da Rodovia. Estavam realizando uma vistoria. Saindo do KM, em uma curva acentuada à esquerda, deparou-se com os Réus efetuando um assalto a mão armada contra um casal. Estava acompanhado de Marcelo e Jurandir. Estavam realizando fiscalizando de dutos de combustíveis da Petrobrás. As vítimas estavam em uma motocicleta preta. Não consegue identificar marca ou modelo, porque foi muito rápido. Duas pessoas estavam na moto. Um rapaz e uma moça, que estava bem assustada. A mulher estava abaixada e o homem estava com as mãos para cima, ambos fora da motocicleta. Um dos roubadores estava em cima da motocicleta e um outro estava am pé, em frente ao rapaz da motocicleta assaltada, com arma de em punho. Os réus possuíam outra moto, além da motocicleta das vítimas. A motocicleta dos réus era branca. Um dos réus estava apontando a arma para as vítimas. Os réus fugiram e escorreram com a motocicleta, por isso realizaram a abordagem de ambos. Não conhecia as vítimas nem os Réus. Reconhece o Réu Wesley Olímpio da Silva como sendo o condutor da motocicleta dos Réus. Aparentemente o outro Réu era quem estava armado. Não consegue reconhecer com 100% de certeza porque estava usando capacete. Trabalha há 15 (quinze) anos como vigilante. Não sabe dizer se alguma casa tinha filmagem ou não. Não agrediu fisicamente algum dos Réus. Nenhum dos seus colegas agrediu os Réus. Visualizou a arma de fogo há menos de 10 metros de distância. Não sabe dizer qual era a arma porque não pegou na mão. Chutou a arma de fogo distante de um dos indivíduos. Acredita que a viatura possui GPS, mas não sabe ao certo.

Em juízo, a testemunha MARCELO ROBSON FREIRE SANTOS disse que se recorda dos fatos. Quando foram verificar o setor da empresa, com a viatura (estavam em três), visualizaram um rapaz na motocicleta com as mãos para o alto. Seu colega disse "o cara tá roubando a moto". Os dois Réus correram para cima da moto. Acha que se assustaram. Os Réus saíram muito rápido, sem direção. Caíram em frente ao carro. Seu colega gritou "ele tá armado". Saíram do carro e chutaram a arma, que depois verificaram ser um simulacro. Chamaram a polícia. Quando foram verificar as vítimas, elas já haviam se evadido do local. Em um primeiro momento apenas desceram do automóvel dois vigilantes. Um colega ficou dentro do carro chamando a polícia, era o Jurandir, o coordenador de serviço. Acionaram a Polícia Militar. Segundo o policial um vizinho já havia chamado. Os policiais chegaram rápido, uns 10 minutos. Não viu ninguém agredindo os Réus, nem populares. A distância que os Réus caíram das vítimas era em torno de uns 10 metros. Era próximo. Não se recorda quais eram as motocicletas. Não consegue se recordar das características da moto, mas acredita que seja de cor preta. Acredita que seja uma motocicleta menor, 125 ou 150 cilindradas.

Em juízo, a testemunha JURANDIR BEZERRA DE LIMA disse que presta serviços para uma subcontratada da empresa Petrobras. Estavam realizando uma inspeção de duto para a empresa. É o coordenador. Depararam-se com os Réus apontando a arma de fogo para uma pessoa, não identificada. Os Réus subiram na motocicleta e saíram bruscamente pela viela. Os Réus se descontrolaram e caíram em sua frente. A moto foi para um lado e os Réus para o outro. O simulacro de arma de fogo caiu perto do carro. Foram em direção ao simulacro para os Réus não pegarem, porque não sabiam que era um simulacro. Posteriormente a polícia militar chegou. Um dos Réus estava com a arma apontada para o casal. A menina estava com a mão para cima e o menino não se recorda como estava. Instantes depois os Réus subiram na motocicleta e tentaram se evadir. Foi um curto espaço de tempo. A cor da motocicleta das vítimas era cinza,

uma 125. O lugar era escuro, com pouca claridade. As vítimas foram embora. Não desceu do carro porque não utiliza colete balístico e o automóvel era blindado. Os réus estavam em outra moto. Fugiram e vieram a cair. Reconhece Wesley como sendo o Réu que dirigia a motocicleta e o Réu Edson como sendo aquele que portava a arma de fogo. Nunca havia visto os Réus. Ninguém da equipe agrediu os Réus. Só abordaram os Réus porque eles caíram na frente deles com a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Precisariam realizar uma manobra pra sair do local, porque a motocicleta dos Réus ficou caída muito próxima ao carro. Estavam há mais ou menos 1m, 1,5m. Subiram na motocicleta, passaram uma valeta e caíram, estavam se descontrolando desde o início. Não sabe dizer se a polícia militar agrediu os Réus. Aparentemente os Réus caíram e se machucaram muito, pois não conseguiram se levantar e pegar a motocicleta para fugir. Um deles tentou se levantar duas vezes. Não realizou o reconhecimento dos Réus na delegacia. Não se recorda de alguém ter chutado da arma. Recorda-se de alguém falar que não era pra chegar perto da arma. Descobriram que era um simulacro quando a polícia militar chegou ao local. Estava ligando para a polícia quando chegaram. Acredita que foram os vizinhos quem chamaram. A polícia chegou muito rápido. Os espaços são pequenos. Se der muito, é 10 m. De onde os Réus caíram não conseguiram avistar as vítimas, porque é uma rua estreita, uma viela. As casas moram rente aos dutos. Os réus estavam no meio do acesso da rua para o duto. Na hora em que viraram viram os Réus e então eles caíram em frente ao carro. A cor da motocicleta dos Réus era preta. Os réus caíram com capacete. Na hora em que caíram, um dos Réus caiu próximo da motocicleta. Na hora em que os Réus tentaram se levantaram já estavam sem capacete.

Interrogado, o Réu EDSON DE OLIVEIRA GOMES disse que disse que conheceu o Corrêu Wesley na pizzaria. Negou a prática dos fatos. No dia recebeu uma ligação de seu amigo Marcelo, por volta das 21h40min para um serviço de pedreiro, ganhando R\$ 100 reais por dia. Naquele momento estava trabalhando e ganhando pouco dinheiro. Achou que seria bom esse trabalho. Perguntou à dona da pizzaria se um entregador de lá poderia realizar um frete. Estavam um pouco perdidos em Cubatão, até que encontraram dois sujeitos em uma motocicleta e pararam para pedir informação. Disse que não era ladrão. Os sujeitos da motocicleta o atropelaram. Os policiais pegaram seus documentos e o alvará de soltura. Só foi na pizzaria porque Wesley trabalhava de dia como mototáxi. Não tinha como chamar como testemunha esse amigo, Marcelo, em juízo, porque perdeu seu contato no telefone celular. Conhecia Wesley há uns 2 meses, da pizzaria. É frequentador de lá. Wesley não é seu amigo. Nunca viu os vigilantes ou policiais. Não confessou informalmente a prática de roubo. Não caíram de motocicleta. Os vigilantes é que os atropelaram com o automóvel. Não viu seu colega com arma de brinquedo também. Já foi condenado por crime de roubo anteriormente. No crime anterior também teve arma de fogo.

Interrogado, o Réu WESLEY OLIMPIO DA SILVA negou os fatos. O Corrêu chegou e pediu se queria fazer uma corrida de mototáxi. Perguntou para sua patroa e ela concordou. Chegando no local um carro o atropelou. Disse para as pessoas que estava fazendo apenas uma corrida. Conhecia Edson da pizzaria em que trabalhava. Pararam no local porque o Réu disse que era o local em que buscaria o dinheiro e iria ficar. Não sabe se o corrêu Edson tinha simulacro. Nem chegou a ver nada.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que os réus praticaram o crime descrito na denúncia.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

As versões dos Réus, discrepantes entre si, inclusive, encontram-se isoladas no manancial probatório.

De outro vértice, registre-se que o relato das testemunhas, vigilantes e policiais militares, são uníssonos, firmes, coerentes e compatíveis entre si. As testemunhas ainda, reconheceram os réus tanto em solo policial quanto em juízo.

Portanto, no tocante à autoria, as testemunhas foram firmes e coerentes, tanto em solo policial como em Juízo, ao narrarem o episódio encetado na denúncia.

Restou suficientemente comprovado, ônus acusatório (art. 156 do CPP), destarte, que no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 23h27, na Avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao nº 445, Jardim 31 de Março, Cubatão, os Réus, agindo em concurso, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram subtrair, para todos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12), uma motocicleta, pertencente à vítima não identificada, não se consumando por circunstâncias alheias as suas vontades.

Os Réus transitavam pelo local dos fatos, em uma moto, marca Honda/CG Titan, placas DZN-1266, momento em que visualizaram um casal, em uma outra moto (Yamaha/Fazer, cor preta) parados e resolveram, então, em conluio, praticar crime patrimonial.

Entretanto, vigilantes da Petrobrás realizavam ronda pelo local, tendo observado a prática delitiva. Ao avistar, então, a aproximação dos mesmos, o Réu EDSON correu em direção à motocicleta, conduzida pelo Réu WESLEY, visando empreender em fuga. No ato, em alta velocidade, WESLEY perdeu o controle da moto, vindo a cair com EDSON, que estava na garupa.

Consequentemente, foram alcançados e presos em flagrante, juntamente com o simulacro de arma de fogo utilizado, não tendo, assim, o crime se consumado.

As vítimas, ao avistarem os vigilantes, vislumbrando a fuga dos assaltantes, saíram do local, sem serem identificadas.

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que "diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perlustra que "toda pessoa poderá ser testemunha". Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, "a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98).

A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser

excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar os acusados – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente aos acusados a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos.

No caso vertido trata-se de roubo na modalidade tentada, como capitulado na denúncia, pois não houve a consumação delitativa, na medida em que não houve inversão da posse da res furtivae (motocicleta).

Tal entendimento encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente, a Súmula nº 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Esse também é o posicionamento adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: HC

91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05; RHC nº 119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10.12.2013)

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade dos comportamentos dos Réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados EDSON DE OLIVEIRA GOMES e WESLEY OLIMPIO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, "caput", todos do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

A) Em relação ao Réu EDSON DE OLIVEIRA GOMES:

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: ostenta maus antecedentes (Proc. n.º9568-67.2004 – fls. 87). c) Conduta social: nada a considerar. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (fl. 86-87 autos nº 1006328.2014). Assim, agravo a pena em 1/6, fixando a intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, há incidência de uma causa de aumento, prevista no inciso II do §2º, do art. 157 do Código Penal. Portanto, majoro a reprimenda em 1/3, tornando-a em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Ato contínuo, diminuo a pena em 2/3, diante do iter criminis percorrido na tentativa (art. 14, parágrafo único do CP). Assim, estabeleço a pena final do réu em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

B) Em relação ao Réu WESLEY OLIMPIO DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora

analisado. b) Antecedentes: não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: nada a considerar. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante da menoridade penal. Entretanto, como a pena foi fixada no mínimo, nada a ser alterado (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, há incidência de uma causa de aumento, prevista no inciso II do §2º, art. 157 do Código Penal. Portanto, majoro a reprimenda em 1/3, tornando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ato contínuo, diminuo a pena em 2/3, diante do iter criminis percorrido na tentativa (art. 14, parágrafo único do CP). Assim, estabeleço a pena final do réu em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada para o Réu Edson, aliada à reincidência e circunstâncias judiciais negativas, deverá a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal).

Para o Réu Wesley o equipamento inicial será o aberto, porque primário e sem qualquer circunstâncias negativas na primeira etapa de dosimetria.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o cometimento do delito com violência física contra pessoa.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Não há bens apreendidos nos autos para serem destruídos.

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.0000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais.

O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, depois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para:

A-) CONDENAR o Réu EDSON DE OLIVEIRA GOMES, qualificado a fls. 61, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, "caput", todos do CP.

B-) CONDENAR o Réu WESLEY OLIMPIO DA SILVA, qualificado a fls. 74, à pena de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, "caput", todos do CP.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado aos acusados, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. Afinal, "caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória" (STJ, RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014), porquanto "a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu" (STF, HC 93.498-MS, Segunda Turma, DJe de 18/10/2012; STJ: AgRg no RHC 47.220-MG, Quinta Turma, DJe de 29/8/2014; e RHC 36.642-RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2014).

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro (art. 98, § 3º do CPC e art. 10 da Lei 1.060/50). Anote-se.

Encaminhe-se cópia da sentença e de eventual acórdão às vítimas (art. 202, § 1º do CPP e art. 399 da NSCGJ).

Expeça-se certidão do convênio DPE/OAB, se o caso.

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

a) lance-se os nomes dos Réus no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intinem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);

c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

P.I.C.

Cubatão, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA